

1507558-75.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... de agentes, de rigor a exasperação da pena do roubo em 1/3, totalizando cinco anos e quatro meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.

Ademais, consoante a alteração dada pela Lei nº 13.654/2018, pela causa de aumento do emprego de arma do crime de roubo, de rigor a exasperação da pena do roubo em 2/3, totalizando oito anos, dez meses e vinte dias de reclusão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1507558-75.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507558-75.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2086651/2022 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 23949362 - 69º

D.P. TEOTONIO VILELA, 2086651 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Matheus Antonio Teodoro De Souza

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

V I S T O S

MATHEUS ANTONIO TEODORO DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos arts. 157, §2º, II e §2º-A, I, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, e art. 244-B do ECA, em concurso material de crimes (CP, art. 69), porque no dia 29 de março de 2022, por volta das 21h10min, na Rua Carmo da Mata, altura do nº 32, São Mateus, nesta Capital, previamente ajustado e agindo com identidade de propósitos com os adolescentes Matheus Henrique Rodrigues dos Santos e Gabriel Henrique Rogério de Lima, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra as vítimas Cilano Marinho Ferreira e Elza Aurora Alves Ferreira, o automóvel TOYOTA/CROSS XRE, placas ECL8B13, avaliado em R\$ 166.000,00 e um aparelho celular da marca Motorola,

avaliado em R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), pertencentes a Cilano.

E ainda, porque nas mesmas circunstâncias de dia, horário e local acima descritas, o acusado facilitou a corrupção dos adolescentes Matheus Henrique Rodrigues dos Santos (16 anos) e Gabriel Henrique Rogério de Lima (17 anos), tendo com eles praticado o roubo acima descrito.

Segundo a denúncia, na ocasião dos fatos, as vítimas estavam no interior do automóvel TOYOTA/CROSS, estacionado no local acima indicado, quando o acusado e os adolescentes bateram no vidro da porta do motorista, com Gabriel empunhando uma arma de fogo, e anunciaram o roubo, determinando que as vítimas desembarcassem do veículo, sob ameaças de morte.

As vítimas, então, desceram do automóvel, oportunidade em que MATHEUS e os adolescentes subtraíram o carro e o celular da vítima e em seguida, se evadiram do local.

Logo em seguida, policiais militares, acionados acerca do roubo, lograram encontrar o veículo da vítima e iniciaram perseguição. Durante o acompanhamento, os agentes acabaram colidindo contra o veículo VW/Polo, placas FLX-4869 e abandonaram o veículo da vítima na Rua Ernesto Manograsso, bem como se evadiram a pé em direção à Rua Doutor José Cioffi.

Ocorre que, após pularem o muro de uma residência, acabaram detidos na Rua Doutor Afonso Splendore.

Realizada busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Contudo, no porta-luvas do automóvel subtraído da vítima, foi apreendida a arma de fogo utilizada durante o roubo - um revólver calibre 32 com a numeração suprimida e uma munição intacta -, além do aparelho celular da vítima.

Na ocasião da abordagem, o acusado e seus comparsas confessaram informalmente os fatos acima descritos.

O réu foi preso em flagrante, sendo decretada a sua prisão preventiva em decisão de fls. 52/54.

A denúncia foi recebida em 19 de abril de 2022 (fls. 73/75).

O réu foi citado (fls. 104), foi apresentada defesa preliminar (fls. 108) e ratificado o recebimento da denúncia (fls. 109).

Durante a instrução criminal foram ouvidas as vítimas, testemunhas de acusação e, após, foi o réu interrogado.

Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Em sede de alegações finais, a representante do Ministério Público postulou a procedência parcial da ação para condenar o réu por corrupção de menores, por duas vezes, mas apenas por um roubo.

A Dra. Defensora, por seu turno, requereu a consideração de um delito de roubo, absolvição pelo crime de corrupção de menores, reconhecimento da atenuante da confissão e da menoridade relativa, aplicação do parágrafo único do art. 68 do Código Penal (fls. 134/138).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito resta comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 39/44 e pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 37/38, bem como do laudo pericial de fls. 116/121.

Assim, o acusado foi preso em poder dos bens subtraídos. Tal situação, como vêm entendendo nossos Tribunais, inverte o ônus da prova, devendo o réu provar a licitude de tal posse, no que não logrou êxito o acusado no presente feito.

Cito:

"PROVA - Roubo - Apreensão da res em poder do acusado - Inversão do ônus probatório: No crime de roubo, a apreensão da res em poder do acusado faz presumir sua responsabilidade, invertendo-se o ônus probatório." (TACrimSP - Ap. nº

1.410.455/6 - São José do Rio Preto - 7ª Câmara - Rel. Salvador D'Andréa - J. 15.1.2004 - v.u.).

"PROVA - Roubo - Apreensão da res em poder do agente, sem explicação hábil e coerente a respeito da posse - Inversão do ônus probatório - Ocorrência: No crime

de roubo, a posse da res em poder do agente, sem explicação hábil e coerente, inverte o ônus da prova, que se torna de sua exclusiva responsabilidade." (TACrimSP - Ap. nº 1.307.177/4 - São Paulo - 14ª Câmara - Rel. Oldemar Azevedo - J. 21.5.2002 - v.u).

A autoria do delito pelo acusado, outrossim, restou incontroversa e comprovada pela prova oral coligida nos autos.

Em Juízo, o réu CONFESSOU a prática do roubo, disse que estava com os menores, que conhecia da escola, e Gabriel estava armado, ele que abordou a vítima, mandou a vítima descer, mostrou a arma de fogo, entraram no carro, ele foi dirigindo, foi no banco de trás. Foram perseguidos pelos policiais, ele parou o carro. Fugiram a pé, foram presos dentro de uma casa. Não sabe quantos anos os menores tinham. Nunca foi processado. Foi roubar porque estava devendo uma motocicleta com a qual caiu. Importante mencionar a importância e a validade da confissão judicial, entendida como de valor absoluto, livre de qualquer vício, ainda que seja o único elemento de prova nos autos:

"PROVA - Confissão judicial - Validade - Reconhecimento - Entendimento de que tem valor absoluto e, ainda que seja o único elemento de prova, serve como base à condenação - Pedido deferido em parte. (...)"(TJSP - Revisão nº 489.255-3/1 - Amparo - 3º Grupo de Câmaras - Relator Carlos Biasotti - J. 31.01.2008 - v.u). Voto nº 8.869 - grifei

"PROVA - Confissão judicial - Validade - Por presumir-se livre dos vícios da inteligência e vontade, tem valor absoluto, servindo como base condenatória, ainda que seja o único elemento incriminador - Recurso improvido."(TJSP - Ap. Criminal nº 993.08.008.515-3 - Jundiaí - 9ª Câmara Criminal - Relator Souza Nery - J. 02.07.2008 - v.u). Voto nº 13.398

A prova produzida pela acusação é suficiente para a condenação nos termos da denúncia.

A vítima Cilano RECONHECEU o acusado em Juízo como autor do delito e disse que foi buscar sua neta na escola, estava estacionado com sua esposa quando o réu e os menores colocaram o revólver em seu lado e o outro ficou do lado de sua esposa, o tiraram do carro, pediram a chave, um quis levar seu relógio, subtraíram seu carro. Viu claramente a arma de fogo. Seu celular estava dentro do carro. Recuperou o celular e o carro, foram localizados pelos policiais. O carro estava danificado, teve que ser guinchado, eles colidiram com outro veículo, ficou no conserto dois meses. Quando vai buscar sua neta não para mais na rua, fica mais perto da saída, ficou temeroso. Tem 73 anos. Eles não chegaram a subtrair seu relógio. Não subtraíram nada de propriedade de sua esposa Elza.

A ofendida Elza RECONHECEU o acusado em Juízo como autor do delito e afirmou que estava com seu marido Cilano no carro esperando a neta, vieram o acusado e mais dois rapazes, quando chegaram no final do veículo eles voltaram e se dividiram, um de cada lado e um atrás. Ele apontou a arma para seu marido e os fizeram descer. O acusado falou "limpa ele", era para tirar tudo que eles tinham, não deu tempo porque a ronda escolar foi atrás deles. O celular de Cilano estava dentro do carro. Não foi subtraído nada dela, mas ficou muito traumatizada, não sai mais sozinha. Tem 72 anos, fez aniversário em maio. Não foi ouvida na Delegacia de Polícia. Importante colacionar, neste passo, os seguintes julgados, salientando a importância da palavra da vítima em delitos como o da espécie, em que, a princípio, não se tem qualquer motivo para incriminar desconhecidos:

"PROVA - Palavra da vítima - Valor - Indiscutibilidade - Na espécie, a negativa dos acusados não encontra suporte em prova que os inocente de modo categórico - Testemunhas arroladas pela defesa não chegaram a infirmar a prova produzida pela acusação - Assim, na valoração da prova, as declarações seguras e insuspeitas da vítima, máxime por encontrarem suporte nos depoimentos colhidos, devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) dos sentenciados - Recurso improvido." (TJSP - Ap. Criminal nº 1.044.211-3/8 - São Bernardo do Campo - 9ª Câmara do 5º Grupo da Seção Criminal - Relator Souza Nery - J. 13.06.2007 - v.u).

Voto nº 11.630 – grifei

“PROVA - Meios - Roubo - Palavra da vítima - Valor - O relato de vítima tem importante relevo, uma vez que os crimes patrimoniais são praticados, não raras vezes, às escondidas de testemunhas, para facilitar sua consumação - Ademais, sendo única pessoa presente, suas palavras são de extrema importância para o deslinde do feito - Entendimento - Recursos defensivos improvidos e recurso ministerial parcialmente provido.”(TJSP - Ap. Criminal nº 1.011.530-3/7 - Ibitinga - 11ª Câmara do 6º Grupo da Seção Criminal - Relator Xavier de Souza - J. 02.04.2008 - v.u).

Voto nº 7.553 – grifei

“PROVA - Depoimento da vítima de roubo - Palavras do ofendido que, reconhecendo o acusado como sendo o agente do delito, não o conhecia anteriormente aos fatos e, por isso mesmo, não tinha motivos para incriminá-lo falsamente - Eficácia - Recurso improvido.”

(TJSP - Ap. Criminal nº 912.658-3/8 - São Paulo - 3ª Câmara Criminal - Relator Moreira da Silva - J. 11.03.2008 - v.u). Voto nº 2.374 – grifei

Assim é que não há de se duvidar das palavras da vítima, sem provas contundentes em contrário, mormente em casos como o em tela, de delito contra o patrimônio no qual há ameaça à integridade corporal de pessoas, considerando o caráter clandestino do crime da espécie.

O fato de a vítima não ter o dever de dizer a verdade não implica na obrigação de se ver suas declarações com reservas, até porque corroboradas pelas palavras de testemunhas.

O policial militar Marcos Fernando Pereira Miranda reconhecendo o réu em audiência, disse que estavam em patrulhamento quando uma viatura da ronda escolar avisou do roubo próximo a uma escola e indicou a direção da fuga, foram ao encalço, apoiando o cerco, em certo momento eles abandonaram o veículo e os viram pulando para dentro de uma casa. Pularam atrás e viram que eles se separaram, os menores foi a uma casa da frente e o acusado para uma casa à esquerda, onde o detiveram. Em revista no veículo localizaram o celular da vítima e uma arma de fogo. A vítima reconheceu a arma.

Suas palavras foram corroboradas pelas de seu parceiro, o policial militar Thiago Bertolli Anastácio, que também reconheceu o réu em audiência.

As palavras dos policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário – não produzida nestes autos – estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais militares há a presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (JTJ 154/302, 159/310), presunção essa aqui não elidida.

Ainda:

“DEPOIMENTO DE POLICIAL. Valor probante. A tese da insuficiência testemunhal, quando emane de agentes da Polícia, consiste em velharia em boa hora mandada ao bolor dos armários de reminiscências especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de ordem alguma para que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a quem o Estado confere a missão importantíssima de coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria prisão. Não se legitima atribuir ao Estado essa insensatez” (RJTJESP 136/477).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF - HC 73518 / SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 26/03/1996 Órgão Julgador: Primeira Turma).

“RECEPTAÇÃO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO - PROVA TESTEMUNHAL (...) DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE - Não há nenhuma

justificativa para se desacreditar do relato apresentado pelos policiais, cujos testemunhos são dotados, a princípio, da mesma credibilidade que os demais (...)
CONDENAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - Sentença absolutória reformada nesta parte RECURSO DA JUSTIÇA PÚBLICA PROVIDO." (TJSP, 3ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0012108-77.2001.8.26.0050, Relator Desembargador Ruy Alberto Leme Cavaleiro, j. 12/06/12 - grifei).

"As declarações dos policiais que atenderam a ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade, uma vez que se trata de agente do Estado, no exercício de função pública, razão pela qual há que se presumir legítimo o relato por ele ofertado, mormente quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos." (TJSP, 15ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0000085-18.2017.8.26.0510, Relator Desembargador Ricardo Sale, j. 02/12/21).

O roubo restou, assim, consumado, ocorrendo a consumação, segundo a jurisprudência pacífica, com o simples desapossamento da res furtiva, mesmo que por um espaço curto de tempo, com a simples inversão da posse do bem, o que aconteceu no caso em tela.

Neste sentido é a súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

E a jurisprudência:

"Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, considera-se consumado o delito de roubo "no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima" (HC 118.407/ SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5ª Turma, DJ 3/8/09). 2. Ordem denegada" (HC 155108/SP Ministro Arnaldo Esteves Lima DJ 03.05.2010).

"O crime de roubo está consumado se o agente, ainda que por breve momento, tem, após o desapossamento violento, a disponibilidade dos objetos. Não é exigível a posse tranquila da res furtiva, bastando que cesse a violência ou a clandestinidade" (STJ/EResp/DF 197848, Min Edson Vidigal, DJ 15.05.2000).

De rigor, ademais, o reconhecimento das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma, descritas pela vítima e confessadas pelo acusado, estando a última também comprovada pelo laudo pericial de fls. 116/121.

Finalmente, há que ser o réu condenado também pela corrupção dos menores Matheus Henrique Rodrigues dos Santos e Gabriel Henrique Rogério de Lima (fls. 03/04) pois comprovado que com eles praticou o crime de roubo. O delito do art. 244-B do ECA é crime formal, não sendo necessária para a condenação por sua infração a efetiva prova da corrupção do menor, bastando que o agente pratique crimes com o inimputável (STF - HC nº 92.014 - SP - Rel. p/ o ac. Min. Menezes Direito - J. 02.09.2008), justamente como ocorreu no presente caso.

Tal entendimento, inclusive, já foi sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no verbete nº 500, de seguinte teor: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

De fato, foram narrados na denúncia dois delitos de corrupção de menores - são dois os menores, Matheus Henrique Rodrigues dos Santos e Gabriel Henrique Rogério de Lima - embora a capitulação da denúncia tenha apenas uma.

Por outro lado, considerando que o crime praticado pelo réu com os adolescentes foi de roubo com uso de arma de fogo, por expressa disposição legal - art. 244-B, §2º, do ECA - a pena das corrupções tem que ser aumentada em 1/3, posto que aquele é delito hediondo desde o advento da Lei nº 13.964/19 (art. 1º, II, "b", da Lei nº 8072/90).

Contudo, não há que se falar em dois roubos, porque somente foram subtraídos bens da vítima Cilano. Este e sua esposa Elza eram maiores de 60 anos quando dos fatos, pelo que deve ser empregada a majorante genérica do art. 61, II, "h", do Código Penal.

Inafastável, assim, a condenação do acusado nos termos da denúncia, por infração aos arts. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal e art. 244-B, §2º do ECA, por duas vezes, em concurso formal de crimes (art. 70 do Código Penal), pois praticados dois delitos mediante uma só ação.

Decidida a tipificação, passo a aplicar ao acusado a sanção cabível, o que faço com base nos critérios estabelecidos no art. 68 do Código Penal.

O acusado é tecnicamente primário, embora responda a outro processo (fls. 49 e 70/72).

Assim, nos termos do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, em quatro anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, para o crime de roubo, e um ano de reclusão para cada um dos delitos de corrupção de menores.

Compenso a confissão com a prática de delito contra idoso com relação ao roubo.

Deixo de atenuar a pena em razão da menoridade relativa do acusado à época dos fatos, por ter fixado as penas-base no mínimo legal (Súmula nº 231 do C. STJ).

Pela causa de aumento do concurso de agentes, de rigor a exasperação da pena do roubo em 1/3, totalizando cinco anos e quatro meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.

Ademais, consoante a alteração dada pela Lei nº 13.654/2018, pela causa de aumento do emprego de arma do crime de roubo, de rigor a exasperação da pena do roubo em 2/3, totalizando oito anos, dez meses e vinte dias de reclusão e pagamento de 21 dias-multa.

Deixo de adotar o postulado pela douta Defensora, de aplicação do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, por entender que se trata de uma discricionariedade do julgador – “art. 68 (...) Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua” (grifei) – e não se pode equivaler as situações de ser roubado por mais de uma pessoa com a de ser roubado com superioridade numérica e também uso de arma de fogo. Tanto é uma situação mais grave esta última que o legislador, com o advento da Lei nº 13.654/18, ao inserir o §2º-A ao art. 157 do Código Penal, quis garantir o aumento em 2/3 da pena daquele que emprega arma de fogo em um roubo, bem como do que emprega explosivo ou análogo, pela periculosidade de tais condutas, independentemente das outras causas de aumento do §2º do mesmo dispositivo legal.

Desta forma, respeitando a vontade do legislador, bem como a individualização das penas, entendendo que não se pode equalizar situações desiguais, ainda mais em delitos violentos, entendo que devem ser aplicadas as duas causas de aumento de pena previstas no art. 157, tal como constantes da denúncia.

De mais a mais, acabar-se-ia por atenuar fortemente o louvável intuito do legislador que, ao editar a Lei 13.654/18, atendendo a reclamos da maior parte da população brasileira, logicamente lograva punir com maior severidade o roubador aparelhado com armas de fogo que, todos os dias, tantas mortes de cidadãos de bem causam no curso de assaltos do estilo. No sentido da possibilidade da cumulação: STJ - HC 472.771/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018.

No caso em tela, as vítimas foram rendidas por três agentes, e com uso de arma de fogo afrontosamente usada, traumatizando ambos os ofendidos, os dois idosos. Enfim, justificado o emprego das duas majorantes.

Neste sentido é o entendimento da Colenda 8ª Câmara do E. TJSP:

“APELAÇÃO CRIMINAL Roubo Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução das penas, com afastamento da causa de aumento de emprego de arma de fogo. Impossibilidade. Provas hábeis a ensejar a condenação, nos termos em que proferida. Bem delineada a incidência da aludida causa de aumento, prescindível, para tanto, a apreensão ou perícia do artefato, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores - Acusação requer a elevação da

reprimenda, aplicando-se cumulativamente o aumento decorrente do reconhecimento do concurso de agentes e aquele relativo ao emprego de arma de fogo - Cabimento Suficientemente demonstrada a incidência de ambas as majorantes, as quais se mostraram igualmente determinantes na concretização do delito, em atenção ao princípio da proporcionalidade e da individualização da pena, é o caso de adequar-se as penas impostas, nos moldes pretendidos pela Acusação Apelo defensivo não provido e apelo ministerial provido. (...) Na terceira etapa, razão assiste ao i. representante do órgão ministerial quando refere que o cálculo da pena fixada comporta reparo. Explico. Ocorre que diante do reconhecimento das causas de aumento de pena previstas no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e §2º - A, inciso I, do Código Penal, entendeu o d. magistrado "a quo" pela aplicação apenas daquela prevista no §2º - A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal, no importe de 2/3 (dois terços), com base no artigo 68, parágrafo único, do mesmo Códex. Data vênia, entendo que tal interpretação veio a beneficiar indevidamente o acusado, mormente porque não se pode simplesmente igualar a ação daquele que age unicamente valendo-se de arma de fogo, com a daquele que, por exemplo, o faz também em concurso de agentes, o que via de regra reduz ainda mais a possibilidade de resistência da vítima e implica em maior possibilidade de sucesso na empreitada criminosa. É necessário, a meu ver, analisar casos desta natureza com especial acuidade, visando resguardar os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Não se pode olvidar que mesmo antes da alteração trazida pela Lei n.º 13.654/2018, permitia-se a cumulação da causa de aumento de emprego de arma de fogo com quaisquer das demais majorantes legalmente previstas no §2º do art. 157 do Código Penal, sendo aplicadas frações variáveis e proporcionais à quantidade daquelas, de acordo com seu reflexo no caso concreto, evidentemente. E o que pretendeu a nova lei, como é cediço, foi conferir às ações criminosas praticadas mediante utilização de arma de fogo, tratamento mais enérgico, compatível com a gravidade peculiar advinda de tal circunstância, sendo, pois, um contrassenso, que se ignorasse, agora, a existência concomitante de causas de aumento outras, que permanecem legalmente previstas e dispostas no parágrafo anterior. Nesse sentido, vem decidindo esta Colenda Câmara: "APELAÇÃO CRIMINAL Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Sentença condenatória pelo art. 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Recurso Defensivo buscando o afastamento das causas de aumento do concurso de agentes e do emprego de arma (§2º-A, inciso I, do art. 157, do Código Penal). Alegação de inconstitucionalidade material da fração de aumento do art. 157, § 2º-A, do Código Penal, por ofensa ao princípio da proporcionalidade, e impossibilidade de cumulação entre as referidas causas de aumento. Pedidos subsidiários de fixação de regime semiaberto e detração da pena. Autoria e materialidade comprovadas Prisão em flagrante Réu que confessou parcialmente a prática delitiva, negando, apenas, o emprego de arma de fogo Vítima que confirmou que o réu praticou o delito de roubo em questão, com a participação de um comparsa e o emprego de armas de fogo, tendo sido ameaçada durante a empreitada criminosa. Réu e comparsa que subtraíram o veículo da vítima e se evadiram, tendo sido encontrados pela Polícia algumas horas depois, na posse do veículo subtraído Acusado que conduzia o carro roubado, e o colidiu durante a perseguição policial Reconhecimento pessoal positivo Palavra da vítima que merece credibilidade Roubo consumado Delito que se consumou com a retirada do bem da esfera de disponibilidade da vítima Crime cometido com violência e grave ameaça. Causas de aumento do concurso de agentes e emprego de arma sobejamente demonstradas pela prova colhida desnecessidade de apreensão da arma de fogo para a configuração da majorante, quando devidamente calcada em outros elementos de prova. Dosimetria Pena-base fixada no mínimo legal. Na segunda fase, inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes Na terceira fase, causas de aumento do art. 157, § 2º, inciso II, e do § 2º-A, inciso I, que são perfeitamente cumuláveis, à luz do disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal a eventual não cumulação de causas de aumento ou de diminuição é faculdade do Julgador, conforme expressamente previsto em lei alegada inconstitucionalidade material da fração de aumento trazida pela Lei nº 13.654/18 que não merece prosperar Legislador que previu fração de exasperação mais gravosa para conduta de lesividade mais elevada (emprego de arma

de fogo), não havendo qualquer afronta ao princípio da proporcionalidade manutenção das exasperações de pena pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, cumulativamente. (...) Recurso da Defesa desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 0048158-09.2018.8.26.0050; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/05/2019; Data de Registro: 24/05/2019 grifos nossos). Com efeito, ao prever que 'no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição (...)', o parágrafo único do art. 68 do Código Penal estende ao julgador uma faculdade (e não um dever). Nessa toada, tem-se o entendimento das Cortes Superiores, bem destacado pela d. Procuradoria Geral em seu parecer: "(...) A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o art. 68, Parágrafo Único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta (...)". (STJ, HC nº 472771/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 13/12/2018). Também nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO São Paulo Apelação Criminal nº 1501213-85.2018.8.26.0567 -Voto nº 39.442 19 CORPUS: CF, ART. 102, I, "D" E "I". ROL TAXATIVO. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COMETIDO CONTRA MENOR (CP, ART. 214 C/C 224, "A") E DE PRODUÇÃO DE PORNOGRAFIA INFANTIL (ECA, ART. 241). (...) IMPUGNAÇÃO DA INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. DOSIMETRIA. REAPRECIÇÃO DOS ELEMENTOS CONSIDERADOS PARA FIXAÇÃO DA PENA NA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO APRECIAÇÃO DO TEMA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE AMPARO LÓGICOTEXTUAL À APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DOS INCISOS I E II DO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. [...] 4. Na espécie, o paciente teve sua pena majorada duas vezes ante a incidência concomitante dos incisos I e II do art. 226 do Código Penal, uma vez que, além de ser padrao da criança abusada sexualmente, consumou o crime mediante concurso de agentes. Inexistência de arbitrariedade ou excesso que justifique a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal. 5. É que art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do quantum exasperado. [...] 7. Habeas corpus extinto por inadequação da via processual. (HC 110.960/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 24/09/2014). E, no caso em apreço, é de ser dito que ambas as majorantes devem ser aplicadas. Sucede que, por um lado, conforme apontou a d. Procuradoria Geral, em consonância com o mencionado entendimento das Cortes Superiores, "não foi apresentada justificativa concreta para a opção pelo aumento único. A bem ver, houve mera invocação abstrata do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, sem que se cogitasse da proporcionalidade da punição em relação aos fatos" (fls. 213). Por outro lado, observa-se que a presença de ambas as majorantes reconhecidas em desfavor do acusado foram de fato determinantes para a rendição do ofendido e consumação da ação criminosa. No caso, não bastasse o delito ter sido perpetrado mediante uso de arma de fogo, os roubadores ainda se valeram da superioridade numérica (pelo menos dois agentes) para ameaçar a vítima, que teve o dinheiro do caixa do estabelecimento subtraído e, também, o veículo de sua propriedade, que se encontrava estacionado em frente ao local. Evidente que um único agente, ainda que munido de arma de fogo, teria encontrado maior dificuldade ou quiçá resistência por parte do ofendido para efetuar tal ação, já que haveria de manter sozinho a vítima subjugada enquanto buscasse, após subtrair-lhe o dinheiro do caixa, adentrar ao veículo que estava estacionado junto à via

pública e sair rapidamente na condução dele. Tais fatores, portanto, se mostram hábeis a justificar, com base no caso específico dos autos (exatamente conforme orienta a jurisprudência das Cortes Superiores), a necessidade de aplicação cumulativa das duas causas de aumento reconhecidas pela r. sentença condenatória, como requer o "Parquet". (TJSP - 8ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal nº 1501213-85.2018.8.26.0567 - Relator Desembargador SÉRGIO RIBAS - j. 5/12/2019 - grifei).

Pela causa de aumento do §2º ao art. 244-B do ECA, aumento a pena de cada uma das corrupções em 1/3, totalizando um ano e quatro meses de reclusão para cada um dos delitos de corrupção de menores.

De rigor, no caso, a aplicação do concurso formal entre o roubo e as corrupções de menores. Tendo em vista que são dois os delitos de corrupção de menores, de rigor o aumento a pena do delito mais grave, do roubo, em 1/3. Contudo, este seria prejudicial ao réu, pelo que, com base no art. 70, parágrafo único, do Código Penal, aplico o concurso material de delitos e somo as penas impostas, totalizando onze anos, seis meses e vinte dias de reclusão e pagamento de 21 dias-multa. Torno definitiva tal pena, à míngua de outras causas de oscilação, mantendo a unidade do dia-multa em seu mínimo legal, tendo em vista a falta de comprovação de boa capacidade contributiva por parte do réu.

Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação, para CONDENAR o réu MATHEUS ANTONIO TEODORO DE SOUZA, qualificado nos autos, como incurso nas penas dos arts. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal e art. 244-B, §2º do ECA, por duas vezes, em concurso formal de crimes (art. 70, parágrafo único, do Código Penal), ao cumprimento da pena total de onze anos, seis meses e vinte dias de reclusão e pagamento ao Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 21 dias multa, com unidade no mínimo legal.

Dada a pena aplicada e considerando que o acusado foi condenado por delito grave e violento, estão ausentes os requisitos subjetivos para a concessão dos benefícios dos arts. 44 e 77 do Código Penal.

Em atenção ao disposto no §2º, "c", e 3º ao art. 33 do Código Penal, determino que o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado, pela gravidade de sua conduta, demonstrada no curso do crime por ele praticado, não merecendo o roubador qualquer tratamento indulgente.

Urge salientar, neste passo, que tem sido entendimento jurisprudencial que:

"Roubo qualificado - Regime carcerário mais gravoso - Crime grave - Conveniência de regime inicial fechado. Diante da gravidade do crime e da periculosidade do agente, pode o Juiz impor regime prisional inicialmente fechado, independente do montante da privativa de liberdade e a primariedade do réu, em observância com as circunstâncias presentes no fato delituoso, em conjunto com aquelas previstas no artigo 59, do Código Penal." (TJSP - 4ª Câ. de Direito Criminal - APL nº 9.211.536-56.2009.8.26.0000 - Ac. 5.335.524 - São Paulo - -Rel. Desembargador Willian Campos - J. 16/08/2011 - grifei)

"Por fim, a despeito da primariedade do réu, foi bem eleito o regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena, sobretudo porque se trata de crime cometido em concurso de agentes e mediante grave ameaça, o que e recomenda enérgica interferência estatal, na esteira, aliás, de entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: 'O regime prisional inicial fechado é o único adequado à espécie, em razão do montante da pena, da gravidade concreta do crime e da personalidade do agente que o prática, motivos que exigem resposta penal enérgica, com a qual não é compatível solução mais branda.'" (Apelação nº 0001833-19.2009.8.26.0655, 11ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Xavier de Souza, julgado em 22/06/2011).'" (TJSP - 11ª Câ. de Direito Criminal - Apelação nº 0081289-43.2016.8.26.0050- Rel. Desembargador Alexandre Almeida - J. 28/02/2018- grifei).

Anote-se também o precedente do C. STJ:

"A jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal é firme no sentido de que a escolha do regime inicial não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum na pena

corporal imposta, devendo ser observadas todas as circunstâncias do caso concreto, sobretudo as contidas no art. 59 do Código Penal ... considerando-se como negativas algumas circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social e consequências do crime) autorizando, assim, a imposição do regime fechado para o início de cumprimento da reprimenda, consoante o disposto no art. 33, §3º, do Código Penal” (HC 240393/BA, Rel. Min. MARILZA MAYNARD, DJ de 24/06/2013, grifos nossos).

Consoante o art. 387, §2º, do CPP, mantenho o regime prisional acima fixado, pois inexistem informações sobre o comportamento carcerário do acusado para a progressão de regime, consoante o art. 112 da LEP. Neste sentido: TJSP, 3ª Câmara Criminal, AC nº0045877-82.2014.8.26.0224, relator Desembargador Luiz Antonio Cardoso; TJSP, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, AC nº0004038-54.2014.8.26.0361, relator Desembargador Luiz Augusto de Sampaio Arruda.

Nos termos do §1º do art. 387 do Código de Processo Penal, considerando presentes os requisitos da prisão preventiva, MANTENHO a custódia cautelar do réu, ante a manifesta periculosidade que apresenta, inalterada a situação fática que determinou a decretação de sua prisão anteriormente, presentes, sem dúvida, os requisitos do art. 312 do CPP, não se justificando, agora que se acolheu a pretensão estatal para condenar o acusado, ordenar a libertação dele, sem prejuízo do conhecimento de eventual apelação a ser interposta.

Recomende-se o réu no local em que se encontra preso.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal; bem como e extraia-se o DNA do(s) réu(s), para identificação de seu(s) perfil(s) genético(s), conforme art. 9º-A da lei n.º 7.210/84.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. R. I. C.

São Paulo, 23 de junho de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA